

1500942-26.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... por atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando que se dedica à atividade criminosa, não fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz que o tráfico era cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, o que enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500942-26.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500942-26.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE JÚNIOR PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

KAIQUE JÚNIOR PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia 25 de junho de 2022, por volta de 09h08min., no cruzamento da Rua América do Norte com a Rua Marcos Mafrinati, Bairro Jardim Esplanada, nesta cidade de Araçatuba/SP, nas imediações de estabelecimento de ensino, o réu trazia consigo e transportava, para traficar, treze gramas e oitenta decigramas (13,8g) de Benzoilmetilecgonina, distribuídos em quarenta e quatro (44) microtubos plásticos de cocaína, bem como cento e um gramas e oitenta e um decigramas (101,81g) de Cannabis Sativa L,

divididos em trinta e seis (36) porções de maconha, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 25/06/2022 (fl. 01). Pela r. decisão de fls. 33/34, foi concedida a liberdade provisória em favor do acusado, com imposição de medidas cautelares. Alvará de soltura cumprido em 26/06/2022 (fls. 55/56).

Devidamente notificado (fl. 111), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 118/121. A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022 (fls. 130/131). O réu foi citado (fl. 158). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 159/162).

Em alegações finais (fl. 166/173), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos moldes da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Na dosimetria da pena, não obstante o acusado seja primário, ele possui passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando que se dedica à atividade criminosa, não fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz que o tráfico era cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, o que enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal. Por fim, pleiteou o perdimento, em favor da União, do veículo GM/Corsa, placa DDJ 3A32, apreendido nos autos, uma vez que foi utilizado para a prática do crime.

Em alegações finais (fls. 175/177), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado por ausência de provas. No caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, bem como o reconhecimento e os efeitos da primariedade do réu. Por fim, pleiteou o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 57/58), laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 59/64), relatório policial (fl. 65/66), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação Rafael de Lima Jordão, policial militar ouvido em juízo (fl. 160), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 02), disse que no dia dos fatos foram acionados via COPOM para averiguação de suspeito próximo à Escola Estadual "Purcina". O veículo foi avistado parado com uma pessoa em seu interior. Afirmou que foi possível visualizar o acusado jogando algo atrás do banco, quando notou a presença dos policiais. Relatou que nada de ilícito foi encontrado com o réu durante sua abordagem, porém, foi localizada uma pochete com entorpecentes dentro do carro. O acusado informou que era de Guararapes/SP e havia pegado emprestado aquele automóvel. Disse que as características e placa do veículo informados pelo COPOM coincidiram com o automóvel usado pelo acusado, o qual estava parado defronte à escola, próximo ao cruzamento. Não conhecia o réu, mas já tinha informações de um veículo com as mesmas características, que praticava a venda de entorpecentes nas proximidades da escola. O acusado afirmou que a droga era dele e

o carro era emprestado, não se manifestando sobre o tráfico de drogas. Disse que o veículo foi removido do local por meio do guincho, não recordando por qual motivo ao certo. Afirmou que o automóvel não estava quebrado ou sem combustível.

A testemunha de acusação Wagner Mosca, policial militar ouvido em juízo (fl. 161), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 04), disse que estava em patrulhamento com o Cabo Jordão quando foram acionados pela Central, informando que no cruzamento entre as vias América do Norte e Marcos Mafrinati, havia um veículo possivelmente com um indivíduo dentro, em atitudes suspeitas. Chegando ao local, notaram que o acusado arremessou um objeto no assoalho do veículo. Na abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, embaixo do banco do motorista foi encontrada uma pochete contendo 44 (quarenta e quatro) eppendorfs de cocaína e 36 (trinta e seis) envelopes pequenos de maconha. O réu informou que era de Guararapes/SP e tinha vindo de uma festa, bem como declarou que o veículo era emprestado, porém, os policiais não conseguiram entrar em contato com o proprietário. Relatou que o acusado, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados até a central de flagrantes. Disse que a placa do automóvel não foi constatada, mas outras informações passadas pelo COPOM coincidiram com o veículo abordado, tratando-se de um GM/Corsa, que estava estacionado defronte à escola. Relatou que o veículo foi puxado para subir no guincho, mas não estava quebrado ou com falta de combustível. Afirmou que o veículo foi rebocado porque não tinham a chave. Disse que encontraram o acusado drogado, não sabendo informar onde estava, sendo que no interior do veículo havia uma lata queimada.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 162), o réu Kaique Júnior Pereira negou a prática do delito. Disse que havia acabado de receber seu pagamento, no dia 23 de junho, e como haveria uma festa em Araçatuba/SP no dia 24, o interrogando pegou R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), um carro emprestado de seu amigo "Wellington" (dono do GM/Corsa) e foi para a cidade. Com o valor em mãos, passou na "Praça das Seiscentas" em Araçatuba/SP para adquirir droga, com finalidade de uso próprio durante a festa. Disse que comprou 50 (cinquenta) pinos de cocaína e 40 (quarenta) de maconha, tendo usado 06 (seis) e 04 (quatro) porções das drogas, respectivamente, totalizando o valor pago de R\$ 350,00 em maconha e R\$ 250,00 na cocaína. Relatou que pagou um preço mais baixo em razão de ter sido vendida por um conhecido. Informou que comprou a droga em pedaços e depois distribuiu em pinos para usar na festa e o restante levar para usar em sua cidade. Após comprar e distribuir as drogas, partiu para a festa, sendo que ao término da festa usou um pouco dos entorpecentes e decidiu voltar a sua cidade. Quando estava em frente ao Supermercado Rondon, próximo à escola, o combustível do veículo acabou. Disse que por estar muito tarde e não conhecer muito bem a cidade, resolveu dormir no carro para buscar gasolina no próximo dia. Relatou que na manhã seguinte, acordou com a abordagem dos policiais. Afirmou que nada foi encontrado na sua posse, sendo que informou aos policiais da existência da pochete embaixo do banco. Disse que explicou aos policiais sobre a festa e o carro, recebendo voz de prisão. Informou que trabalha em um frigorífico da sua cidade e recebe R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais. Relatou que levou um total de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para Araçatuba/SP, sendo que gastou R\$ 600,00 em droga, R\$ 50,00 em bebida e R\$ 50,00 para entrar na festa. Afirmou que neste dia não estava muito consciente, em razão de ter exagerado no consumo dos entorpecentes e bebidas. Esclareceu que dentro do carro, após comprar a droga à granel, levou 50 (cinquenta) pinos vazios para distribuir o entorpecente e ir usando durante a festa com seus conhecidos. Disse que fracionou a droga dentro do carro. Relatou que mora em Guararapes/SP com seus pais e ajuda no sustento da casa, pagando as contas de luz e internet. Nunca fez tratamento para o uso de entorpecentes. Admitiu que tem 02 (duas) passagens anteriores na adolescência, por tráfico de drogas em Guararapes/SP, além de estar sendo processado por roubo. Afirmou que não é registrado no frigorífico, pois trabalha de forma terceirizada, mas pediu ao seu patrão que adiantasse o pagamento em 07 (sete) dias para poder ir à festa. Disse que consome de 05 (cinco) a 15 (quinze) pinos de cocaína e 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) gramas de maconha

diariamente, estando inconsciente na maior parte do dia, sendo que trabalha nessas condições. Informou que nunca viu os policiais antes dos fatos.

Encerrada a instrução processual, restou demonstrado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas.

Os policiais militares confirmaram os fatos narrados na inicial acusatória. Foram uníssonos ao relatar em solo judicial que foram acionados via COPOM para averiguar um veículo estacionado defronte a uma escola, em atitude suspeita. Chegando ao local, as testemunhas avistaram o acusado jogando algo no assoalho do carro, no momento que ele notou a presença dos policiais.

De acordo com os agentes públicos, no interior do veículo foi encontrada uma pochete que continha 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína e 36 (trinta e seis) de maconha, sendo que ao ser questionado, o réu informou que era de Guararapes/SP e a droga lhe pertencia, bem como o veículo era emprestado. Contudo, a testemunha Rafael de Lima Jordão afirmou em juízo que já tinha informações de um veículo com as mesmas características do acusado, que praticava a venda de entorpecentes nas proximidades da escola.

Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais militares, uma vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, bem como pelos laudos periciais de fls. 57/64.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 02/05), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição relevante que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

Ao contrário do que sustenta a defesa, embora os policiais tenham divergido quanto à dinâmica da retirada do veículo, tenho que tal divergência deve ser debitada ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos agentes públicos, o que não afasta a responsabilidade penal do acusado.

Neste passo, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, visto que, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestarem testemunho sob o compromisso da lei.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito, tendo em vista que as testemunhas afirmaram em juízo que não conheciam o acusado, versão corroborada pelo réu em seu interrogatório.

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Quanto ao acusado, em que pese tenha admitido a propriedade dos entorpecentes localizados no veículo, verifica-se que negou estar vendendo os entorpecentes nas imediações da escola, afirmando que havia comprado a droga no dia anterior para consumo próprio.

Ainda de acordo com o réu, ele reside em Guararapes/SP, mas veio para uma festa em Araçatuba/SP, sendo que consumiu parte dos entorpecentes na mencionada festa e quando retornava para casa, o combustível do veículo acabou, razão pela qual acabou estacionando-o defronte à escola para dormir, pois estava sob o efeito de drogas e bebida alcoólica, ocasião em que foi acordado pelos policiais militares.

Observa-se, contudo, que sua versão exculpatória restou isolada nos autos, sendo infirmada pela prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que o acusado tivesse adquirido grande quantidade e variedade de entorpecentes para consumo próprio (13,80 gramas de cocaína, distribuídas em 44 microtubos plásticos, bem como 101,81 gramas de maconha, divididas em 36 porções).

Também não é crível que tenha pegado o veículo emprestado de terceiro para ir até uma festa, sendo que ao retornar ficou sem combustível e, coincidentemente, estacionou-o defronte à Escola Estadual “Professora Purcina Elisa de Almeida”, como afirmou em seu interrogatório em juízo, considerando que o réu ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 77/78 e 93/105).

De igual modo, a versão apresentada em juízo, de que consome de 05 (cinco) a 15 (quinze) pinos de cocaína e 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) gramas de maconha diariamente é incompatível com a alegação de que auferia por mês a quantia de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), por seu trabalho em um frigorífico, uma vez que não conseguiria sustentar o alegado vício, considerando que afirmou ter pagado R\$ 600,00 pelos entorpecentes (valor que alegou corresponder apenas a 50 pinos de cocaína e 40 porções de maconha) e ainda auxilia seus pais nas despesas de casa.

Nesse ponto, soa também fantasiosa e inverossímil a narrativa de que trabalha de forma terceirizada num frigorífico e que seu patrão teria “adiantado” o pagamento em 07 (sete) dias para o acusado ir à festa, bem como que adquiriu a cocaína à granel de um conhecido, razão pela qual teria pagado um preço mais baixo, e depois fracionou o entorpecente dentro do veículo em 50 (cinquenta) pinos vazios que trouxe consigo.

Quanto à alegação da falta de combustível no veículo, sua narrativa foi infirmada pela palavra dos policiais militares, os quais foram uníssomos em solo judicial ao afirmar que o carro não estava quebrado ou sem combustível, sendo necessário guinchá-lo porque a chave não foi encontrada, conforme declarou a testemunha Wagner Mosca.

Registre-se, por fim, que toda a narrativa apresentada pelo acusado em juízo não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova colhido nos autos, tendo em vista que não arrolou uma testemunha sequer para corroborar sua versão – como o suposto amigo de quem teria pegado o veículo emprestado (“Wellington”), ou amigos que estavam na mencionada festa com o réu, bem como algum funcionário ou patrão do frigorífico que alegou trabalhar na cidade de Guararapes/SP –, tratando-se de versão fantasiosa, frágil e destituída de qualquer suporte probatório que lhe dê sustentação.

Destaca-se, ainda, ao contrário do alegado pela defesa, que o réu não produziu nenhuma prova acerca da origem lícita do numerário que afirma ter utilizado para adquirir os entorpecentes.

Pois bem. O modo como as drogas estavam acondicionadas e a quantidade apreendida configuram que se destinavam ao tráfico. Isto porque, foram apreendidas 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, perfazendo o total de 13,80 gramas da

substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, além de 36 (trinta e seis) porções de maconha, perfazendo o total de 101,81 gramas da substância entorpecente Cannabis Sativa L, conforme laudos periciais de fls. 57/64.

Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse sendo, portanto, desnecessário que o agente seja flagrado em atos de mercancia ou na posse de apetrechos comumente utilizados para a prática do delito, conforme sustentado pela combativa defesa.

A propósito, sobre o tema o E. TJ/SP já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP63/316, 70/371 e 97/512).

De mais a mais, ainda que se admitisse que o réu também fosse usuário das drogas - conforme alegado por ele em seu interrogatório -, tal fato, por si só, não exclui a prática do crime, provado no caso vertente, uma vez que é muito comum que alguns usuários revendam o entorpecente para sustentar o próprio vício, circunstância que não afasta a tipicidade e responsabilidade penal.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a majorante também restou comprovada, uma vez que as testemunhas e o próprio acusado confirmaram em juízo que ele estava com o veículo estacionado defronte à Escola Estadual "Professora Purcina Elisa de Almeida", sendo irrelevante o fato de que a ocorrência se deu num sábado, em dia e horário que não havia aula. Ressalta-se, ainda, que o policial militar Rafael de Lima Jordão afirmou em juízo que já tinha informações de um veículo com as mesmas características do acusado, que praticava a venda de entorpecentes nas proximidades da escola.

Diante de tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação de crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação é medida que se impõe, uma vez que segura a prova da responsabilidade penal do agente, não havendo se falar em manifesta inocência ou insuficiência probatória, como pleiteado pela defesa, uma vez que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as condutas do réu, consistentes nas ações de "trazer consigo" e "transportar" os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontram-se inseridas no rol descrito no "caput" do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Analisando os autos, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em favor do acusado.

Conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça, a inserção no ordenamento jurídico da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) teve por escopo diferenciar aquele agente que não é dedicado à prática de ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de entorpecentes com maior potencialidade lesiva à sociedade, sendo que a aplicação da benesse não pode ocorrer de forma desmedida, mas somente em casos singulares, quando o agente preenche cumulativamente todos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena (REsp nº 1.380.741/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, em que o acusado possui 02 (duas) passagens na Vara da Infância e Juventude Infracional pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico no ano de 2021, sendo-lhe aplicadas medidas socioeducativas de acordo com as certidões de fls. 78 e 93/105 (processos nº 1500394-35.2021.8.26.0603 e 1501207-96.2020.8.26.0603), bem como está sendo processado por roubo majorado praticado em setembro/2022, ou seja, três meses após o presente delito (processo nº 1501433-33.2022.8.26.0603 – consulta realizada no site do TJ/SP).

Sendo assim, diante dos vários apontamentos pretéritos, que guardam razoável proximidade temporal com o delito em questão – o acusado foi submetido à medida socioeducativa de internação em abril/2021 (fl. 103), com término de cumprimento em fevereiro/2022 (cf. consulta aos autos nº 0003294-32.2021.8.26.0032 – fl. 78), ou seja, dias antes de atingir a maioridade penal e 04 (quatro) meses antes da prática do delito, sendo que três meses depois foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado –, bem como as demais circunstâncias do crime e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedica habitualmente às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, se posicionou o C. STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.” (STJ, EResp nº 1.916.596/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021, g.n.).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRIOS E AÇÕES PENAS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INCABÍVEL. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC nº 762.383/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022, g.n.).

Em razão de todo o acima exposto, restou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 74/77), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal. Portanto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 06). Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o delito foi cometido pelo acusado nas imediações da Escola Estadual "Professora Purcina Elisa de Almeida". Portanto, aumento a pena no patamar mínimo legal, em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo.

Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Inviável, no caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como delineado na fundamentação supra, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), excepcionalmente, pois o correto seria a fixação do regime fechado, considerando no presente caso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, o montante da pena imposta, a natureza e quantidade das drogas apreendidas (13,80 gramas de cocaína e 101,81 gramas de maconha), tenho que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis), por estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, inciso I e 77, "caput", ambos do Código Penal.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu KAIQUE JÚNIOR PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime semiaberto para o início do cumprimento.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem mantidas as circunstâncias que levaram a responder ao processo até aqui solto.

Por fim, DECLARO o perdimento do veículo GM/Corsa Wind, placa DDJ 3A32, apreendido nos autos (fl. 17) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que foi utilizado para a prática do delito em questão, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003).

P. R. e I.

Araçatuba, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA